

1501018-54.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... à prisão. Concordou que a pena do tráfico possa ser atenuada pela confissão parcial, que não se deu aos demais delitos. Discordou da redução da pena do tráfico, ante a grande quantidade de drogas apreendidas a indicar maior dedicação do acusado a esse crime, discordando também da substituição das penas corporais pelas penas restritivas de direitos, fixando-se regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501018-54.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000729

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2129926/2022 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Janderson dos Santos Fagundes

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

JANDERSON SANTOS FAGUNDES, qualificado às fls. 12 e 14/15, está sendo processado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, no artigo 329, caput, e no artigo 129, caput, §12, todos combinados na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque no dia 12 de maio de 2022, por volta das 10h30, na Estrada Pedreira Alvarenga, altura do nº 2369, bairro do Eldorado, nesta cidade de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 800 embalagens plásticas contendo 569 gramas da droga cocaína, bem como 608 embalagens plásticas contendo 74,558kg (setenta e quatro quilogramas e quinhentos e cinquenta e oito gramas) a droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 40/42 e laudo de constatação provisória de fls. 57/59, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo, JANDERSON opôs-se à execução de ato legal mediante violência física contra os policiais civis Fernando Antônio

Brighenti Pereira, Eder Donizete Rosa e Antônio José dos Santos Peres, funcionários públicos estaduais, competentes para executá-lo. Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, JANDERSON SANTOS FAGUNDES ofendeu a integridade corporal do policial civil Fernando Antônio Brighenti Pereira, provocando-lhe as lesões corporais descritos no laudo pericial de fls. 10/11, cuja natureza será oportunamente indicada com a juntada do laudo de exame de corpo de delito complementar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.68/72). Não sendo hipótese de arquivamento nem condição de aplicar qualquer benesse ao réu, a denúncia foi recebida em 04/07/2022 (fl.115) e certificadas a notificação e a citação positivas do Réu (fls.141 e 184). O d. Advogado apresentou defesa inicial as fls. 126/136, com pedidos de liberdade provisória e concessão de justiça gratuita, indeferidos, este último, até que se juntasse declaração de hipossuficiência e prova da mesma, o que foi feito às fls. 172/178 e, portanto, devidamente demonstrada, concedo a justiça gratuita ao acusado. Anote-se.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima dos mínimos legais, diante da enorme quantidade e nocividade da droga cocaína, e das consequências das lesões à vítima policial Fernando, quem ficou afastado do trabalho, fazendo sessões de fisioterapia, e ante a atuação de todos os policiais para deterem o réu que resistiu à prisão. Concordou que a pena do tráfico possa ser atenuada pela confissão parcial, que não se deu aos demais delitos. Discordou da redução da pena do tráfico, ante a grande quantidade de drogas apreendidas a indicar maior dedicação do acusado a esse crime, discordando também da substituição das penas corporais pelas penas restritivas de direitos, fixando-se regime prisional fechado ao tráfico e semiaberto para os dois crimes previstos no Código Penal, além da aplicação do disposto no art. 63 da lei Antidrogas, com a perda do veículo usado no tráfico, sem possibilidade de recurso em liberdade.

Já o d. Advogado reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória e porque seu cliente não sabia que o rapaz que lhe abordou e que estava num carro normal e se vestia sem farda nem usava distintivo, seria um policial, tanto que achou que estaria sendo roubado. Subsidiariamente, requereu que as penas-base fossem fixadas no mínimo legal, com a atenuante da confissão, e o redutor da pena ainda, além de sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls.40/42, nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente as fls.57/59 e 114), ambos positivos para cocaína e maconha.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.02/07), através de investigações obtiveram a informação de que haveria o transporte de drogas pela

região de chácaras do bairro Eldorado, em Diadema e que para este transporte se utilizariam do veículo Hyundai/HB20 de cor prata e placas QOM-1481, então de posse dessa informação diligenciaram com duas viaturas, uma caracterizada e outra descaracterizada até a referida região da cidade e passaram a procurar pelo veículo informado. Por volta das 10h30min, conseguiram visualizar o veículo passando na Rua Doutor José Silvio de Camargo, momento em que passaram a acompanhar o mesmo até a chegada da outra viatura, porém o condutor do veículo percebeu a presença policial e passou a acelerar, momento em que decidiram por abordá-lo na Estrada Pedreira Alvarenga, próximo ao nº 2369, após o cercarem. O policial Fernando que estava mais próximo se aproximou da porta do condutor teve a sua arma agarrada pelo condutor do veículo, que a puxou, ocasionando a quebra do vidro. Relatou que o policial Fernando conseguiu desvencilhar a sua arma do condutor do veículo, que rapidamente desembarcou do veículo, jogando o seu celular no chão e pisando no mesmo, no mesmo instante em que avançava sobre o policial, entrando em luta corporal, e ambos foram ao solo, causando lesões no aludido policial, até que conseguiram conter o condutor do veículo, usando de força moderada para isso. Imobilizado com o uso de algemas, o mesmo foi identificado como sendo JANDERSON SANTOS FAGUNDES. Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado com ele, porém, ao verificarem dentro do veículo Hyundai/HB20 de cor prata e placas QOM-1481, foram localizados mais de 200 embalagens com fragmentos vegetais assemelhados a MACONHA e outras com um pó branco assemelhado a COCAÍNA. Questionado sobre as drogas, o indiciado assumiu estar as transportando, que a entregaria na zona norte de São Paulo e que receberia o valor de R\$ 2.500,00 para fazer este serviço.

Sob o crivo do contraditório essas testemunhas reiteraram suas alegações primeira. O policial Eder Donizete confirmou que através de investigação sabiam que um veículo HB 20 estaria carregando entorpecente. Foram em duas viaturas até o bairro Eldorado, de chácaras. Visualizaram o veículo. Houve um acompanhamento. Ele percebeu e empreendeu fuga. As duas viaturas, uma caracterizada e outra não, fizeram acompanhamento por aproximadamente um quilometro. Detido, o policial Fernando foi fazer a abordagem e o réu entrou em luta corporal para tirar a arma de fogo dele. Ajudaram na prisão. Ele quebrou o celular dele, destruindo a prova de algum outro parceiro dele. Revistado o carro, havia um monte de entorpecente. O conduziram ao DP. Questionado, ele confessou o transporte da droga, por dois mil reais e não delatou os demais parceiros, tanto que quebrou o celular para destruir provas. Às reperguntas da defesa respondeu que a viatura descaracterizada é usada para investigação e pode ser que o indivíduo saiba por estar no crime e conseguir identificar o veículo, e por isso muitas vezes perdem investigação por causa disso. As pessoas do crime organizado já conhecem algumas viaturas descaracterizadas, usadas há anos aqui em Diadema, cerca de seis, e por isso os carros já são conhecidos pelos criminosos. O policial Fernando foi o primeiro a se aproximar do réu e se identificou como policial e o réu agarrou a mão dele querendo tomar a arma dele, e o machucou, desembarcando do carro, quebrando o celular, e veio para cima do policial novamente, quando então o pé do Fernando também restou lesionado. Acredita que o vidro do carro do lado do motorista onde o acusado estava, estaria aberto para dali ele poder puxar a arma da mão do policial Fernando. O réu foi algemado porque queria fugir.

Igualmente, o policial civil e vítima Fernando Pereira retificou que receberam informação de que o veículo HB20 cujas placas tinham, estaria transportando drogas. Foram em duas viaturas, uma caracterizada e outra não. Viram o veículo e houve acompanhamento. Ele percebeu a presença policial e acelerou. Ligaram sinais luminosos e sonoros e ele não obedeceu. Até que fizeram o cerco. Desceu para abordá-lo, e o réu agarrou sua arma e quebrou o vidro do carro que estava entreaberto, e por isso machucou sua mão, cortando-a. O réu desembarcou e veio para cima de si para tentar tomar a arma e lhe empurrar e investiu contra si para lhe derrubar e caiu no chão, machucando o dedo do pé, e com a ajuda de seus parceiros, o algemaram. No banco traseiro do veículo localizaram embalagens com as drogas,

mais de oitenta quilos de maconha além da cocaína. Foi ao PS onde soube que fraturou o dedão do pé e arranhões nos braços. Reconhece o réu, e questionado, ele confessou que receberia dois mil e quinhentos reais para transportar a droga até a Rodoviária do Tietê. Ele disse que fez uma entrega e conheceu um cara que lhe contratou para tal transporte. Às reperguntas da Acusação, respondeu que ficou um mês com o pé imobilizado e ainda tem que fazer fisioterapia. As drogas estavam no porta malas e no banco do carro. Às de Defesa, respondeu que houve um acompanhamento pela viatura descaracterizada já conhecida dos criminosos porque sem usam o mesmo carro, que já é conhecido portanto. Acompanharam o réu por aproximadamente um quilômetro. A viatura descaracterizada não é identificada por um cidadão comum de bem, mas as pessoas da criminalidade sabem, porque tem duas antenas e outros detalhes, que eles sabem. Cercaram o réu com as duas viaturas. Desembarcou e foi na direção dele, para a porta do motorista. O vidro estava entreaberto. Ordenou para ele descer, e ele puxou sua arma. Puxou de volta para ele não pegar sua arma, e nisso quebrou o vidro. O réu desceu e veio na sua direção, e ambos caíram no chão, ele ainda tentando tomar a arma da mão dele.

Neste sentido foi o depoimento judicial do policial Antonio Peres , quem contou que estava no apoio e ao ver que o réu foi identificado, foi acompanhar a diligência. Viu o policial descer e abordar o réu no vidro e nisso o réu desceu do carro e houve um empurra-empurra, uma resistência do réu, e por isso correu para ajudar o policial e imobilizar o acusado e algema-lo. Dentro do carro tinha uma quantidade enorme de entorpecentes, mais de oitenta quilos, algumas drogas fracionadas, no porta malas e dentro do carro, e era maconha e cocaína. Indagado, confessou ter pego as drogas em Diadema e ia levar na Zona Norte. Reconhece o réu, quem disse que ganharia dois mil reais pelo transporte das drogas. Às reperguntas da defesa, respondeu que estava numa viatura caracterizada, e não ficou perto para não ser identificado pelo réu, e vinha atrás da outra viatura, descaracterizada, uma Palio Weekend. Viu a perseguição que se deu por aproximadamente um quilometro. O policial Fernando foi até a janela do veículo e houve luta corporal entre eles, porque o réu desembarcou também e houve entrevero entre eles.

O réu, em solo policial (fl.12) respondeu que trabalha como entregador da plataforma IFOOD e que em uma de suas entregas conheceu um cliente, cujo nome não sabe dizer, com quem teria comentado estar apertado, então esse cliente lhe ofereceu para fazer o transporte de alguma coisa, cujo conteúdo não sabia dizer até a sua prisão, que para este serviço pagaria ao mesmo o valor de R\$ 2.500,00, que os produtos seriam retirados em Diadema, nas proximidades do local aonde foi abordado e as entregaria no bairro Tietê em São Paulo, declarando que não vai informar os endereços exatos. Declarou que após o recebimento dos sacos, que foram carregados no porta malas do seu veículo Hyundai/HB20 de cor prata e placas QOM-1481, seguiu o seu caminho, quando percebeu a aproximação policial, então acelerou, na tentativa de se evadir até ter o seu veículo fechado pela viatura mais à frente. Declarou que no momento da abordagem, tentou mais vez se evadir, seu aparelho celular que já estava quebrado caiu, terminando de quebrar, mas foi contido pelos policiais e trazido até esta Delegacia de Polícia. Declarou que possui Carteira de Habilitação, porém que não se encontrava de posse da mesma.

Em juízo o acusado alegou que não tentou agredir nenhum policial. Foi ele quem bateu e quebrou o vidro do seu carro. Até achou que fosse um assalto. Saiu do carro e encontrou com a viatura da Polícia Civil, quebrou seu celular e se jogou no chão. Não tentou pegar a arma do policial. O vidro do seu carro estava fechado. Estava transportando droga, assume, mas não tentou agredir ninguém, nem machucou ninguém. Questionado sobre os três policiais terem dito que houve um entrevero entre ele e o policial Fernando, que se atracaram, negou. O carro é seu e estava pagando parcelado. Questionado se tentou se evadir como disse em solo policial, negou, pois assim que ligaram a sirene e o farol, parou e já se entregou. Já foi processado por ter se evadido da viatura por não ser habilitado e estar pilotando moto à trabalho, e como não sabia que tinha que ter ido atrás do processo. Seu carro estava cheio de multa e por isso não dava mais para trabalhar de Uber. Às reperguntas da Defesa

sobre a abordagem policial, disse que depois de ter pego o material no condomínio Sete Praias, com um senhorzinho de óculos, e saiu. Já veio o carro descaracterizado, jogou na sua rente, veio o cara armado e estourou o vidro de seu carro, desceu e correu porque achou que ia ser roubado, mas a viatura policial veio, deu sinal, e então parou, jogou seu celular no chão, e se entregou, se jogou no chão. O carro era isofilmado, uma Palio Weekend, e o policial veio lhe abordar e deu um tiro também. Usava cordão de ouro, com roupa comum, e não tem certeza se estava com distintivo. O vidro do seu carro estava fechado. Quebrou porque o policial deu uma pancada em seu vidro. Seguiu com o vidro quebrado. O policial deu um tiro para cima. Seguiu até a viatura caracterizada dar sinal e então parou o carro, desceu, quebrou o celular, e se entregou se jogando no chão, sendo agredido fisicamente pelos policiais. Os policiais disseram que se ele tivesse se entregado, já estaria em casa. Ficou machucado, mas não falou para o legista, por medo. E os policiais que o levaram para audiência de custódia também lhe agrediram fisicamente, e não pode falar nada, não teve chance de falar nada.

Logo, o interrogatório com a confissão parcial do acusado, especificamente no que diz respeito ao crime de tráfico, não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais.

É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ora: o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, HC 76.608-0).

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Embora o acusado alegue estar transportando drogas por necessidade do dinheiro que receberia para tanto, não comprovou e nem lhe favorece, ante a desproporção entre os interesses, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza e a excessiva quantidade de drogas permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido atinente a esse delito é inarredável, até porque confessado pelo agente.

No que diz respeito aos delitos de resistência à prisão e o de lesão corporal dolosa contra o policial Fernando, em que pese a negativa de autoria do réu. Mas

como visto, o ofendido e as testemunhas presenciais afirmaram que o acusado tentou fugir da abordagem acelerando seu veículo, e depois que não teve saída porque foi encurralado pelas viaturas, tentou pegar a arma de fogo da mão do policial Fernando, puxando-a, e Fernando puxou de volta para que o réu não lhe desarmasse, e assim quebraram o vidro do carro. Não satisfeito, o réu desembarcou e veio na direção do mesmo policial-vítima, tentando retirar mais uma vez o armamento de sua mão, caindo os dois ao solo, entrando em luta corporal, necessitando da intervenção dos outros policiais que, com emprego de força moderada, conseguiram conter o réu e algema-lo.

Portanto, tem-se que o acusado não apenas reagiu de forma ativa à prisão, como lesionou o aludido policial, machucando-lhe na mão e no dedo do pé, como se comprova inclusive de suas declarações, e dos depoimentos dos colegas de farda, e principalmente do laudo pericial de fl. 112 que constatou lesão de natureza leve na mão da vítima, como se vê inclusive da fotografia de fl. 52. No mais, ressalto que o §2º do art. 329 prevê a aplicação cumulativa das penas desses dois crimes, na hipótese como a desses autos.

Dito isso, tem-se que a negativa de autoria do réu acerca dos crimes de resistência e lesão corporal ao policial, não procede, e restou completamente divorciada do contexto probatório.

Ora, a versão trazida hoje apenas, de que um homem veio para cima de si com um carro normal, desembarcou e quebrou o vidro do seu carro com uma arma, pensando assim que se tratava de um roubo, é pouco crível, já que uma pessoa não conseguiria quebrar o vidro de um carro em andamento, dado que o réu não explicou se estava parado nem o motivo, já que negou ter obedecido a ordem de parada feita por um carro descaracterizado. Ainda, prossegue o réu dizendo que por achar que seria roubado, seguiu com o carro, mesmo tendo o tal homem dado um tiro para cima. Entretanto, fatos tão graves como estes, estranhamente, não foram trazidos à baila em solo policial, sendo que o normal e correto seria o réu já ter dito à autoridade policial que acreditava que estava sendo roubado e por isso não parou, pois se verdadeira fosse essa história.

Não bastasse isso, tenta o réu fazer crer que apenas parou o carro depois que uma viatura caracterizada deu ordem de parada, e então já se entregou, desembarcando e deitando-se ao chão, sendo lesionado pelos policiais. Mas como visto, não foi isso que se sucedeu. Segundo prova testemunhal, o réu ao desembarcar veio na direção do policial Fernando e entrou em luta corporal com ele, tentando desarma-lo, sendo contido pelos outros dois agentes da lei, de modo que não se entregou, foi contido com o auxílio dos demais agentes da lei.

E nem se alegue que a viatura descaracterizada não tenha sido identificada pelo réu, e por isso ele não teria parado e sim acreditado se tratar de um roubo, já que a viatura é usada pela polícia há mais de cinco anos em Diadema, infelizmente já sendo conhecida pelos criminosos daqui.

E quanto a alegação de ter sofrido agressões por parte dos policiais, tal arbitrariedade não foi mencionada ao juiz da audiência de custódia, feita justamente para apurar esse tipo de atitude negativa da polícia, tanto que sequer o laudo pericial de fl. 67 trouxe qualquer lesão ao réu, e sem prova contrária, tem-se por inverídica. Assim como a alegação do réu de que também teria apanhado dos outros policiais, os que o levaram a audiência de custódia, sem fazer prova do que alega, como lhe compete esse ônus, quanto mais quando o contexto probatório não lhe favorece, nem as provas vocais, nem a pericial (vide laudo de exame de corpo de delito do réu - fl. 67), e como já dito, se verdadeira fosse essa versão, o normal e correto seria o preso já ter dito que sofreu maus tratos dos policiais ao juiz da custódia e ao Defensor Público que lhe defendeu, e não apenas depois de ter tido tempo e condições de amadurecer versão mais satisfatória aos interesses da Defesa particular.

Dito isso, adianto que será considerada na primeira etapa de mensuração de pena, a aumentá-la, a mentira do réu quanto aos delitos de resistência e lesão ao policial trazida em seus interrogatórios, dado que suas versões não foram simplesmente negar os crimes, mas o réu mentiu e alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como eles se passaram, visando uma injusta absolvição, o que demonstra distorção de caráter e ausência de senso moral, ao apontar, indevida e injustamente, o policial Fernando como sendo um suposto roubador por não estar fardado e por ter quebrado o vidro do seu carro e disparado um tiro com sua arma de fogo, para depois ainda alterar os fatos da prisão alegando que teria sido agredido fisicamente pelos policiais que lhe prenderam e também pelos policiais que o encaminharam a audiência de custódia, sem fazer prova disso, nem mesmo da materialidade, já que não apresentou nenhuma lesão.

Ainda acerca da mentira, ressalto que o interrogatório é um meio de defesa e de prova, devendo o réu respeitar as regras do processo dentre as quais a da lealdade, da ética, da boa-fé, pois o processo é um instrumento para a realização da Justiça. Portanto o acusado, ao mentir deliberadamente, extrapola os limites da autodefesa – que não é absoluta – demonstrando deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode em razão disso, proferir decisão equivocada e, pois, injusta, para que o réu, se valendo de engodos, vise escapar de uma justa condenação, revelando assim sua personalidade amoral e dissimulada, a justificar a elevação da pena em primeira fase. Caso contrário, estará incentivando o réu a mentir, dado que sua mentira não lhe causaria prejuízo e ainda poderia livrá-lo de uma condenação justa, o que seria melhor que ficar em silêncio, induzindo em erro o juízo, ferindo a dignidade da justiça e acusando os policiais de terem extrapolado quando da abordagem e que teriam cometido arbitrariedades, sem qualquer elemento que pudesse abonar sua sustentação, o que é mais sério ainda.

Sobre o tema vide doutrina e julgados recentes:

- 1- (...) Parece-me, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isso já há uma circunstância atenuante genérica – , mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isso fosse algo normal e aceitável..." (Andrey Borges de Mendonça – Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194).
- 2- (...) Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgados, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade. (Des. José Raul Gavião de Almeida, Apelação 00771651-20.2015, da 6a. Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, em 30/11/2017).
- 3- (...) demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém flagrado no cometimento de infração penal não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações. (TJ/SP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625. 8a. Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, j. 28/11/2019).
- 4- Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se

utilizou da mentira - subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade - com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando assim, a dignidade da Justiça (TJSP - Ap. Crim. 0001317-32.8.26.0618, j. 3/10/2019, da lavra do ilustre Desembargador Zorzi Rocha da 6a. Câmara de Direito Criminal).

5- Nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com o direito à mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo, demonstrando com isso, além de má índole. (Processo Criminal n. 0003339-30.2014.8.26.0372, 1a. Vara Judicial de Hortolândia - ilustre Juiz de Direito Luis Mário Mori Domingues, j. 21.01.2015).

6- Cabe notar que o e. Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamentos recentes, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos das Apelações Criminais ns: 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto; 0000640-36.2016.8.26.0618, conforme voto do ilustre Desembargador Walter da Silva; 0002205-19.2013.8.26.0625, 15a. Câmara de Direito Criminal, j. 08/08/2019, de relatoria do ilustre Desembargador Ricardo Sale Júnior; 0001091-27.2017.8.26.0618, 8a. Câmara de Direito Criminal, j. 05/12/2019; 0000037-05.2017.8.26.0625, da ilustre Desembargadora Ivanna David.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observado o disposto art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito de lesão, restando a vítima afastada do trabalho por um mês e ainda se submete à sessões de fisioterapia, além da resistência ter se dado não apenas contra um policial, mas uma equipe de três agentes da lei que tiveram que intervir para segurar o réu, que queria fugir, somado à mentira trazida por ele acerca de como a abordagem se deu, tentando fazer crer que os policiais foram arbitrário e cometeram excessos ilícitos contra si, além da excessiva quantidade de narcóticos apreendidos (mais de 1.400 invólucros totais), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas e considerando o princípio da proporcionalidade, ou seja, quanto mais drogas maior a pena, tudo a justificar a fixação, em primeira fase, das penas base acima dos mínimos legais, acrescido 1/3, perfazendo para o delito de tráfico: 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, e 04 meses de detenção para a lesão, e 02 meses e 20 dias de detenção para a resistência.

Na segunda fase, ausente circunstância agravante para qualquer dos três crimes. Presente a atenuante da confissão no que diz respeito apenas ao delito tráfico, a reduzir a pena desse em 1/6, alcançando 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa. Não há que se falar em confissão para os demais delitos que se mantém inalterados nessa etapa.

Na terceira fase, só concorre causa de aumento de 1/3 da pena da lesão corporal (§12), porque praticada contra autoridade, no exercício de sua função, perfazendo 05 meses e 10 dias de detenção. Sem causas de diminuição de qualquer das penas, até porque o privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, ainda se trate de réu primário, não faz jus ao beneplácito legal, considerando a apreensão de droga cuja natureza da cocaína apreendida, de alto poder lesivo à saúde humana por altamente viciante, e o transporte de excessiva quantidade e variedade de drogas indica não só a maior dedicação do réu à traficância ilícita, como ser pessoa de confiança, integrante de organização criminosa.

Somo as penas conforme art. 69 do CP, totalizando 05 anos, 06 meses e 20 dias de

reclusão e 555 dias-multa, mais 08 meses de detenção.

Fixo o regime fechado para cumprimento da reprimenda de reclusão (tráfico), e o semiaberto para os dois outros, a teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, considerando a alta quantidade da pena para o primeiro, mas também a preponderância da natureza e da quantidade da droga, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional. (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019. E o regime intermediário aos crimes apenados com detenção, diante das circunstâncias judiciais negativas, a também autorizar regime mais gravoso.

E por isso incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação das condutas do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade a conduta, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida. Ademais, o crime de lesão foi praticado com violência física à pessoa, a afastar a benesse, e o de resistência, nesse mesmo cotejo. Não bastasse isso, artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado, sem comprovada residência, sendo incongruente soltá-lo, inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal se considerarmos a suspensão do feito nos termos do art. 366 do CP pelo qual o réu não respondeu e acabou por prescrever, a indicar que não pretende ficar preso e cumprir pena, tanto que resistiu à prisão. Adenans: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em

liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Reconheço a custódia cautelar do Condenado desde a data do fato, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos e a falta de atestado de bom comportamento carcerário atualizado. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal do acusado, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Ademais, a prisão não perdura sequer quatro meses.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra JANDERSON SANTOS FAGUNDES, qualificado às fls. 12 e 14/15, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, no artigo 329, caput, e no artigo 129, caput, §12, todos combinados na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, e o faço para condená-lo à pena de 08 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 05 anos de reclusão em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 555 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O condenado não poderá apelar em liberdade. O recomendo no cárcere em que está. Sem condenação a custas processuais diante da concessão da justiça gratuita ao réu nessa data, diante dos documentos justados às fls. 126/136 e 172/178. Anote-se.

Decreto a perda do veículo apreendido nestes autos, pois utilizado na consumação de crime grave, tudo com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao IIRGD e TRE.

P.I.C.

Diadema, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA